

1512392-40.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Constrangimento ilegal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512392-40.2020.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512392-40.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Constrangimento ilegal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3089497/2020 - 04º D.P. AMERICANA, 14459701 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO HERCULANO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

DANILO HERCULANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 158, "caput", c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, tentou constranger alguém, mediante grave ameaça, a fazer ou tolerar que se fizesse alguma coisa, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2021 (fls. 52/53).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 106), apresentando defesa (fls. 110).

Na audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas. O réu deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 156/157 e fls. 200).

Em memoriais (fls. 204/208), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a consequente condenação do réu.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora (fls. 211/214) requereu a improcedência da ação, ou a fixação de pena mínima.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A preliminar de inépcia da denúncia, não deve ser reconhecida, tendo em vista que a prefacial atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia. Segundo o entendimento da jurisprudência: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. Ao contrário do alegado, foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente e demais acusados, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas. A tese de insuficiência das provas de autoria ou participação resume-se à alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. (...). 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.767/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 21/10/2019)

DENÚNCIA - Requisitos do art. 41 do CPP - Prolixidade e luxo de pormenores - Desnecessidade: 62 - A exigência do Código de Processo penal, em seu art. 41, quando a exposição do fato criminoso com "todas as suas circunstâncias", não significa que a denúncia deva ser prolixa, contendo pormenores existentes nas peças do inquérito. RJDACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 134 RELATOR: - SILVA RICO.

DENÚNCIA - Atendimento aos pressupostos da Lei Processual Penal - Inépcia - Inocorrência: 216(a) - A denúncia onde se acha presente fato normal, atribuído a culpados, cumpre os reclamos da Lei Processual Penal, não podendo ser taxada de inepta. RJDACRIM VOLUME 24 OUTUBRO/DEZEMBRO/1994 PÁGINA: 416 RELATOR: - SILVEIRA LIMA

DENÚNCIA - Ausência de descrição pormenorizada da participação de cada co-réu - Nulidade - Inocorrência: 279 - Inocorre nulidade da peça inicial, pelo fato do Promotor não descrever pormenorizadamente a participação de cada co-réu no evento criminoso, máxime quando tal atitude, em nenhum momento, impediu o réu de exercer sua defesa. RJDACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 486 RELATOR: - CANELLAS DE GODOY.

Ainda, não se verifica qualquer nulidade, tendo em vista que a instauração do incidente de insanidade, pode ser efetuado a qualquer tempo do processo. Há que se analisar, também, que não consta qualquer solicitação da defesa para tanto, seja na

defesa preliminar ou na audiência de instrução.

Segundo HÉLIO TORNAGUI, o verbo ordenará, empregado no artigo 149 do Código de Processo Penal não pode levar o intérprete a concluir que o juiz tem a obrigação de atender sempre ao requerimento de exame pericial. Lembra o ilustre penalista que o artigo 184 do mesmo diploma legal que, com exceção do exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a realização de perícia:

"... quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Se o juiz verifica que o pedido é meramente protelatório ou tumultuário, cabe-lhe policiar o processo e negar a perícia. Do contrário, não seria um requerimento, mas uma imposição... Seria uma incoerência que o juiz pudesse repelir o laudo (CPP, art. 182) e não pudesse negar o exame" ("Curso de Processo Penal", Saraiva, 1980, p. 254).

Segundo Vicente Grecco Filho:

"... a dependência para consubstanciar a base biológica da inimputabilidade deve ser objetivamente diagnosticada como doença mental, isto é, psicopatia ou enfermidade da mente, de fundo físico ou psíquico ou ambos ("Tóxicos", Saraiva, 4ª ed., 1984, pág. 131).

No mais, o réu foi revel e os depoimentos das testemunhas, em Juízo, não indicam que o réu possuísse qualquer perturbação da mente.

Só se justificaria o exame de dependência se o juiz suspeitasse ser o réu dependente de drogas, que revelasse características próprias de quem está com a saúde mental perturbada, o que não é o caso dos autos.

Em suma, tal exame só é determinado quando, em concreto, for reputado necessário pelo julgador, qualquer que seja o crime cometido, não caracterizando o seu indeferimento cerceamento de defesa. Nesse sentido, o entendimento dos nossos tribunais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA NÃO REALIZADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Quanto à nulidade do processo, conforme o reconhecido na manifestação ministerial, importa reconhecer que "a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017), sendo incompatível com a via do habeas corpus analisar as razões fáticas que motivaram o julgador a indeferir o incidente" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). 3. (...). 5. Writ não conhecido. (HC 521.458/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 3. No caso, o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. 4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do

paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 5. (...). (HC 446.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - INDEFERIMENTO MOTIVADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PLEITO PREJUDICADO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica quando não houver indício de nenhuma perturbação que interfira na capacidade de entendimento da ilicitude da conduta e na autodeterminação. Caracterizam-se os maus antecedentes quando o trânsito em julgado for posterior, mas o crime for praticado anteriormente ao em análise. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. Resta prejudicado o pleito de isenção das custas processuais diante do deferimento da benesse na sentença. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.15.008308-5/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 29/01/2020)

ENTORPECENTE - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade quando não demonstrada a existência de deficiências mentais - Declaração de voto parcialmente vencido (TJSP) RT 728/534

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tráfico de entorpecente - Exame de dependência do acusado à droga - Indeferimento - Magistrado que o entendeu desnecessário, diante da conduta daquele no processo - Nulidade pretendida - Inexistência - Recurso de "habeas corpus" não provido - Inteligência do art. 22, § 5º, da Lei 6.368/76 (STF - Ement.) RT 546/450

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Inexistência - Exame de dependência ao tóxico - Não realização do pleiteado por acusado de tráfico de entorpecente - Ausência de prova, sequer de receita médica, a justificá-lo - Paciente que se apresenta em juízo em aparente condição de normalidade psicossomática - "Habeas corpus" denegado (Ement.) RT 565/311

No mérito, a ação penal é procedente.

Extorsão é o fato de o sujeito constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

A objetividade jurídica principal é a inviolabilidade do patrimônio. Porém, como se trata de crime complexo, ou seja, a fusão de várias figuras típicas, tem por objetos jurídicos a vida, a integridade física, a tranquilidade de espírito e a liberdade pessoal.

A extorsão tem semelhanças com o crime de roubo, em face dos meios de execução, quais sejam, a violência física e a grave ameaça. Diferem, no entanto, com relação ao comportamento da vítima, que é imprescindível na extorsão e não o é no roubo.

Há pontos de semelhança entre a extorsão e o constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, porquanto em ambos o sujeito emprega violência ou grave ameaça contra a vítima, para que esta faça ou deixe de fazer alguma coisa.

A diferença está no fato de que na extorsão, o sujeito assim age com o objetivo expresso de obter indevida vantagem econômica. Se a vantagem é devida, o réu responde pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo

345 do Código Penal.

A extorsão atinge a consumação com a conduta típica imediatamente anterior à produção do resultado visado pelo sujeito, ou seja, no instante em que a vítima faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa.

A tentativa só é possível quando o sujeito passivo, não obstante constrangido pelo autor por intermédio da violência física ou grave ameaça, não realiza a conduta positiva ou negativa pretendida, por circunstâncias alheias à sua vontade. Independentemente da concepção material ou formal do crime de extorsão, a tentativa é admissível. Cumpre destacar que, ainda que as demais elementares estejam todas presentes, a extorsão não estará consumada se a vítima, em razão do constrangimento sofrido, não se submeter à vontade do autor, fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa. Para sintetizar, o simples constrangimento, apesar de tratar-se de crime formal, sem a atuação da vítima (fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa), não passa de tentativa. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 3. 7ª ed., pág. 149)

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos de fls. 02/03.

A autoria também é indubitosa.

O réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos.

A vítima C.B, ouvida em Juízo, alegou que enquanto parou o veículo no semáforo, foi abordada pelo acusado, o qual encostou no carro e o exigiu-lhe dinheiro. Narrou que disse ao réu, o qual estava bem nervoso, que não tinha dinheiro, sendo que ele bateu no vidro e pediu qualquer coisa de valor. Ficou nervosa, e enquanto mexia na bolsa, viu que o réu simulou que estava armado, momento em que o semáforo abriu e andou com seu veículo, sendo que o réu tentou puxar a maçaneta para abrir a porta, e acelerou o veículo, tendo o réu caído ao solo. Declarou que acionou a polícia, a qual apreendeu o réu. Reconheceu a pessoa detida pelos policiais como sendo o réu. Informou que o réu aparentava estar nervoso, mas não proferiu palavras desconexas, não percebendo estar sob efeito de drogas ou alterado. Por fim, entendeu a ação do réu como uma exigência e não um pedido.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

Ademais, não se revela ineficaz a ameaça, mesmo que efetuada sob a égide de ofensas a honra ou simulação de arma, apenas porque a vítima, ao invés de ceder à exigência, buscou o auxílio policial.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação.

APELAÇÃO - EXTORSÃO - PALAVRA DA VITIMA - VALOR: Em crimes desta natureza, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e desde que não haja indícios de falsa inculpação. APELAÇÃO - EXTORSÃO - POLICIAIS MILITARES QUE SE APRESENTAM COMO POLICIAIS DO DENARC PARA EXIGIR VANTAGEM INDEVIDA SOB AMEAÇA DE "PLANTAR" DROGAS EM PROPRIEDADES DAS VÍTIMAS - PROVA COLHIDA MEDIANTE ESCUTA TELEFÔNICA AUTORIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES - NULIDADE - INOCORRÊNCIA: Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio, imbuído do senso de justiça, admite a gravação de conversa telefônica mantida por um dos interlocutores com sua autorização, o que não se confunde com interceptação telefônica, que é aquela feita por terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. APELAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE: A extensa prova oral e material comprova com suficiência, a responsabilidade penal dos agentes, sendo incabível falar-se em absolvição. (TJSP; Apelação Criminal 0006117-71.2011.8.26.0050; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal

Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/03/2013; Data de Registro: 18/06/2013)

"embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. (AgRg no REsp 1644247/R0, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)" (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

Apelações Criminais - Extorsão - Sentença condenatória - Pretensão defensiva voltada à absolvição por falta de provas - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados - Depoimentos da vítima e dos policiais valiosos na elucidação dos fatos - Recurso defensivo improvido. Pretensão ministerial para que seja reconhecida a forma consumada do crime e a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena - Admissibilidade - Crime que se consuma independentemente da obtenção da vantagem - Réu reincidente - Necessária a fixação de regime mais gravoso - Apelo ministerial provido. (TJSP; Apelação Criminal 0100689-48.2013.8.26.0050; Relator: Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2016; Data de Registro: 01/08/2016)

Os guardas municipais ouvidos informaram que foram acionados pela vítima, a qual relatou que ao parar o veículo, tendo em vista o semáforo estar vermelho, veio um indivíduo entre os carros, encostou o rosto no vidro e gritou que queria dinheiro. A vítima informou, ainda, que ficou nervosa, e enquanto tentava pegar moedas, olhou para o réu, o qual estava com a mão embaixo da blusa, simulando estar armado, nesse momento o semáforo abriu, e a vítima acelerou o carro, sendo que o réu ainda tentou abrir a porta do veículo, segurando a maçaneta. Narraram que dirigiram-se ao local, e localizaram o réu, o qual continuava no semáforo pedindo dinheiro aos motoristas, e tentou evadir-se ao avistar a viatura, mas foi detido e conduzido a Delegacia. Por fim, informaram que o réu é conhecido pela prática de delitos contra o patrimônio e aparentava estar normal e lúcido, tendo ficado agressivo no momento da abordagem.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, não restando qualquer dúvida quanto a veracidade dos depoimentos do policial e da vítima.

Pelas circunstâncias a exigência de contribuição para o motorista em semáforo fechado, somada a exacerbada reação quando da negativa, caracterizou, além de intimidação, uma nítida ameaça à integridade física e tentativa de coação à vítima. APELAÇÃO CRIMINAL - Extorsão - Tentativa reconhecida na sentença - Materialidade e autoria comprovadas - Impossibilidade de desclassificação do delito para mero crime de ameaça - Comprovado que a grave ameaça foi empregada para obter vantagem econômica, no intuito de obrigar a vítima a fazer o que não queria - Redução da pena - Inadmissibilidade - Necessidade de preservação do regime inicial semiaberto, fixado na sentença, em face da reincidência e dos maus antecedentes do réu - Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0017031-79.2015.8.26.0625; Relator:

De Paula Santos; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito subsidiário de desclassificação para a forma tentada. Descabimento. Inviabilidade dos pleitos formulados. Provas. Materialidade arrimada nas peças de instrução. Autoria certa. Reconhecimento seguro formulado pela vítima em ambas as fases da persecução penal, com respaldo nas provas, idôneas e eivadas de presunção relativa de veracidade, obtidas a partir dos relatos dos policiais civis. Valor seminal da palavra da vítima na elucidação dos fatos. Malgrado a negativa judicial do réu, o acervo probatório, sólido e calcado em provas não destronadas por álibi ou contraprova, é apto a infirmar a pretensão absolutória. Dolo específico extraído do próprio fato. Consumação verificada. Crime que se esgota com a própria exigência indevida, ainda que dela obtenha o agente efetiva vantagem ilícita. Súmula nº 96 do C. STJ. Precedentes. Condenação mantida. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0093102-04.2015.8.26.0050; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

EXTORSÃO. Crime praticado por "flanelinha". Conduta de constranger motorista, mediante grave ameaça, a pagar R\$20,00 para permitir o estacionamento de veículo automotor na via pública. Tipicidade. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa isolada. Condenação fundada na palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Ameaça comprovada. Conduta configuradora de ilícito administrativo e penal. Independência entre as respectivas responsabilidades. Condenação mantida. Embargos rejeitados. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0075845-63.2015.8.26.0050/50000, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Data: 06 de agosto de 2019)

Apelação. Extorsão. Flanelinha que mediante grave ameaça constrange motorista a pagar R\$ 10,00 para estacionar o veículo - Adoção do voto do eminente Relator Sorteado que desprovia o recurso do réu, alterando-o apenas para fixar o regime prisional inicial aberto. (TJSP; Apelação Criminal 0232027-09.2010.8.26.0000; Relator: Pedro Menin; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2013; Data de Registro: 28/05/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158, CAPUT DO CÓDIGO PENAL- GUARDADOR DE VEÍCULO (FLANELINHA) EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PARA ESTACIONAR AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA - ATITUDE INTIMIDATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DE CONDUTA NÃO RECONHECIMENTO CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA AO CRIME DE EXTORSÃO. REGIME FECHADO DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA MORA, BEM COMO A GRAVIDADE DO CRIME IMPÕE A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0010984-89.2012.8.26.0562; Relatora: Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2014; Data de Registro: 24/06/2014)

Desta forma, a ameaça firmou-se quando exigido o dinheiro, na via pública, com simulação de arma de fogo. Não há dúvida que a ameaça, implícita ou na forma de ofensas, tira o motorista do seu sossego, caracterizando o constrangimento ilegal que integra o tipo da extorsão.

No entanto, a ação da vítima, acelerar o veículo quando da abertura do semáforo, impediu a produção do resultado visado pelo sujeito. Desta forma, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

TACRSP: "O crime de extorsão admite tentativa, vez que há iter a percorrer, sendo passível de interrupção, configurando-se o conatus quando, apesar do emprego de

meio idôneo, o agente não consegue que a vítima faça, tolere que se faça, ou deixe de fazer alguma coisa" (RJDTACRIM 25/152)

RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. TENTATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade. 2. Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.094.888, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, data do julgamento: 21 de agosto de 2012).

EXTORSÃO - GUARDADOR DE VEÍCULO (FLANELINHA) - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PARA ESTACIONAR AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA - VÍTIMA QUE EMBORA INTIMIDADA NÃO CEDEU AO CONSTRANGIMENTO - TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA. (TJSP; Apelação Criminal 0012656-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015)

Diante do conjunto probatório, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 14/40) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 14/40. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa.

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena de 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido, que aproximou-se sobremaneira da consumação perfazendo assim um total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade por estar respondendo solto ao presente processo.

Por fim, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, além da reincidência, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por faltar ao réu o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu DANILO HERCULANO DOS SANTOS à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 08 (oito) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 158, "caput", c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA